

NUR 'IZZATI BINTI 'ALA
lwn
MOHAMAD FAID MUZAHID BIN ALI

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Abas bin Nordin (Ahli Panel) Pada 23 Ogos 2024/18 Safar 1446H]

Kes Permohonan Semakan No.: 2404-A0010-003-0046

[Permohonan Semakan di bawah Seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon: Siti Marlina binti Shikh Ibrahim
(Tetuan Lina & Associates)

Peguam Responden: -Tiada-

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 4/4/2024 melalui notis permohonan dan affidavit sokongan bagi menyemak prosiding permohonan interim hadanah yang difailkan oleh Responden melalui kes Permohonan No.: 2312-H0610-431-0829.

PERMOHONAN

[2] Perintah-perintah yang dipohon adalah sebagaimana berikut:

- i. Mahkamah ini menyemak permohonan Responden untuk mendapatkan suatu perintah interim hadanah melalui kes Permohonan No.: 2312-H0610-431-0829 berdasarkan seksyen

68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

- ii. Prosiding perbicaraan kes tersebut digantung sehingga permohonan ini selesai diputuskan.
- iii. Mahkamah ini mengawardkan kos ke atas Responden sebanyak RM20,000.00 kerana ketakaturan yang berlaku dalam permohonan interim tersebut.
- iv. Lain-lain perintah yang difikirkan munasabah dan suai manfaat.

FAKTA KES

- [3] Pemohon dan Responden berkahwin pada 27/5/2011 di Johor dan bercerai pada 15/11/2023 di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Barat, Selangor. Hasil perkahwinan, pihak-pihak dikurniakan empat orang anak iaitu seorang anak lelaki dan tiga anak perempuan.
- [4] Pada 15/12/2023 Responden telah memfailkan permohonan hak jagaan interim hadanah bagi anak-anak tersebut di mahkamah bicara melalui kes Permohonan No.: 2312-H0610-431-0829.
- [5] Pemohon yang tidak bersetuju dengan permohonan tersebut telah memfailkan afidavit jawapan pada 13/2/2024 dan kemudiannya diikuti dengan afidavit balasan oleh Responden pada 4/3/2024. Afidavit balasan tersebut juga telah berjaya diserahkan kepada Pemohon pada tarikh yang sama.

- [6] Pada prosiding sebutan di hadapan Penolong Pendaftar pada 14/3/2024 Pemohon telah menyatakan hasratnya kepada YA Hakim Bicara untuk menyoal balas Responden berdasarkan affidavit yang telah difailkan menurut seksyen 118 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 (selepas ini dirujuk sebagai “ETMMS”). Namun telah dibantah oleh Responden.
- [7] Prosiding kemudiannya dibawa ke hadapan YA Hakim Bicara dan telah mengarahkan kedua-dua pihak memfailkan hujah bagi menentukan kebolehterimaan pemakaian seksyen 118 ETMMS dalam prosiding permohonan interim.
- [8] Pemohon yang tidak berpuas hati dengan pemfailan prosiding interim tersebut serta arahan yang dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara kemudiannya telah memfailkan permohonan ini.

ALASAN SEMAKAN

- [9] Merujuk kepada notis permohonan dan affidavit sokongan, Pemohon menyatakan alasan-alasan kepada semakan ini adalah sebagaimana berikut:
- i. Tindakan Responden memfailkan permohonan hak jagaan interim berdasarkan peruntukan seksyen 196 dan 197 ETMMS adalah tidak tepat dan tidak selaras dengan kehendak undang-undang.
 - ii. YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila mengarahkan pihak-pihak memfailkan hujahan berkenaan pemakaian seksyen 118 ETMMS.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[10] Kami berpuas hati berdasarkan kepada status kes yang masih dalam prosiding dan kedua-dua alasan yang dikemukakan adalah melibatkan isu tatacara, maka ia menepati kriteria untuk sesuatu kes itu disemak. Hal ini sebagaimana panduan yang dijelaskan dalam kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (semakan) No. 14000-003-0033-2012 di Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dalam kes tersebut Panel Rayuan telah memberi panduan berkenaan kes-kes yang boleh disemak adalah sebagaimana berikut:

- i. **Kes yang masih dalam prosiding, iaitu menyemak prosiding yang dijalankan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah;**
- ii. Kes yang telah selesai diputuskan, iaitu menyemak:-
 - a) Proses yang digunakan oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam membuat sesuatu keputusan;
 - b) Keputusan itu sendiri disemak atas alasan ia menyalahi Hukum Syara' atau Undang-Undang.

[11] Panduan tersebut kemudiannya telah diperkukuhkan lagi melalui Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 (Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah) pula telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak. Antara lain Arahan Amalan ini menyatakan:

1. **Jika kes belum diputuskan**, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, **proses semakan boleh dilaksanakan.**

[12] Berdasarkan panduan ini serta alasan-alasan yang dikemukakan, maka isu-isu yang perlu diputuskan adalah seperti berikut:

- i. Sama ada pemakaian seksyen 196 dan 197 ETMMS dalam permohonan hak jagaan anak secara interim menepati kehendak undang-undang atau sebaliknya wajar diputuskan dalam semakan ini atau tidak.
- ii. Sama ada tindakan YA Hakim Bicara mengarahkan pihak-pihak memfailkan hujahan bagi menentukan kebolehterimaan pemakaian seksyen 118 ETMMS dalam prosiding permohonan interim adalah suatu kekhilafan atau tidak.

Isu pertama

[13] Prinsip dalam sesuatu semakan adalah untuk memperbetul atau menghalang kesilapan dari sudut tatacara mahupun keputusan hakim. Hal ini sebagaimana panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes *Mokhtar bin Yusup lwn. Nurin binti Abdullah [2013] JH36(2)* yang antara lain menyatakan:

“Proses semakan adalah semata-mata untuk **menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi nas-nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan undang-undang yang sedang berkuat kuasa.**”

[14] Menurut Pemohon, Responden telah tersalah arah apabila memfailkan tindakan interim hadanah berdasarkan seksyen 196 dan 197 sedangkan ia sepatutnya difailkan menurut seksyen 201 ETMMS yang merupakan

peruntukan khusus berkaitan permohonan interim hadanah. Pemohon menyatakan seksyen 197 ETMMS adalah bersifat umum yang terpakai bagi apa-apa permohonan interim. Namun begitu, penelitian kami kepada rekod prosiding menunjukkan ia bukanlah isu yang pernah dibangkitkan di mahkamah bicara dan hanya dikemukakan dalam semakan ini. Ini bermakna YA Hakim Bicara tidak pernah dikemukakan persoalan ini dihadapannya untuk diputuskan.

- [15] Pada hemat kami, Pemohon sepatutnya membangkitkan isu ini lebih awal sama ada melalui affidavit jawapan atau bantahan awal. Namun perkara tersebut tidak berlaku. Sebaliknya Pemohon telah membuat jawapan berdasarkan affidavit Pemohon. Dalam hal ini kami berpandangan sekiranya Pemohon beranggapan tindakan Responden memfailkan interim hadanah melalui peruntukan seksyen 196 dan 197 ETMMS sebagai suatu ketidakpatuhan prosedural, maka ia sepatutnya dibawa ke hadapan YA Hakim Bicara untuk diputuskan terlebih dahulu sebelum disemak atau dirayu. Oleh yang demikian, pada peringkat ini tiada keperluan untuk kami memutuskan isu tersebut.

Isu Kedua

- [16] Pemohon menyatakan tindakan YA Hakim Bicara mengarahkan pihak-pihak memfailkan hujah adalah tidak tepat. Menurut Pemohon, apabila terdapat permohonan untuk affidavit Responden diperiksa balas, YA Hakim Bicara sepatutnya memerintahkan agar suatu notis pemeriksaan balas difailkan dan menetapkan tarikh perbicaraan sebagaimana kehendak seksyen 118 ETMMS.

- [17] Bagi memutuskan isu ini kami sekali lagi telah merujuk kepada rekod prosiding dan mendapati arahan YA Hakim Bicara tersebut dibuat apabila wujudnya bantahan daripada Responden. Menurut Responden, Pemohon gagal mengemukakan sandaran undang-undang yang kukuh untuk membuat pemeriksaan kepada afidavit Responden.
- [18] Pada hemat kami, arahan YA Hakim Bicara adalah bertujuan memberi peluang kepada pihak-pihak mengemukakan sandaran undang-undang dan hukum Syarak sebelum menentukan kewajaran pemakaian seksyen 118 ETMMS tersebut. Walaupun Pemohon menyatakan hasratnya untuk memeriksa afidavit Responden ia tidak bermakna YA Hakim Bicara perlu terus bersetuju dan membenarkan permohonan tersebut lebih-lebih lagi jika ia dibantah.
- [19] Dalam hal ini sukacita kami kemukakan pandangan Panel Rayuan Syariah Negeri Melaka di dalam kes **Shariah binti Omar lwn Nazaruddin bin Ramli, Kes Mal (Semakan) No: 10000-003-0005-2012** [tidak dilaporkan] yang telah mengulas mengenai keperluan hujah di dalam sesuatu kes iaitu:-

”Dari sudut fungsi proses penghujahan dalam perbicaraan, ia semata-mata untuk menarik perhatian Hakim Bicara terhadap fakta yang dibentangkannya. Ia juga **boleh menarik perhatian Hakim Bicara agar merujuk kepada otoriti-otoriti yang dikemukakan dengan tujuan merit kes berpihak kepadanya.** Namun, hujah pihak-pihak pula tidak boleh diterima secara terus oleh Hakim Bicara tanpa melalui proses ujian berasaskan kehendak sebenar undang-undang dan hukum syarak. **Dengan itu, bolehlah dibuat kesimpulan bahawa hujah pihak-pihak merupakan suatu proses membantu Hakim Bicara sebelum membuat keputusan dan bukan berupa sumber utama para Hakim membuat keputusan.** Rujukan fakta berkaitan perkara yang dituntut mestilah kepada keterangan Pemohon dan Respondan serta keterangan

sokongan berupa keterangan saksi atau dokumen. Hanya melalui sumber-sumber tersebutlah Hakim akan menilai samada suatu tuntutan atau permohonan boleh diluluskan atau tidak. Atas dasar itulah dalam penghakiman para Hakim lazim dinyatakan bahawa hujah sesuatu pihak itu diterima atau ditolak.”

- [19] Sepanjang penelitian kami kepada afidavit Pemohon, kami juga tidak menemui apa-apa sandaran undang-undang dikemukakan bagi meyakinkan kami bahawa pemfailan hujahan sebagaimana yang diarahkan adalah suatu kecacatan prosedural yang tidak dapat dipulihkan.
- [20] Kami ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa telah menjadi prinsip yang mantap dalam mana-mana pertikaian melibatkan persoalan undang-undang maka mahkamah sewajarnya memberikan peluang seluas-luasnya kepada kedua-dua pihak berhujah. Kegagalan berbuat demikian hanya akan menghalang keadilan semulajadi (*natural justice*) kepada pihak yang dinafikan haknya. Hal ini bertepatan dengan hadis Rasulullah SAW ketika mengutuskan Saidina Ali menjawat jawatan Qadi ke Yaman dimana Rasulullah SAW telah bersabda:

فإذا جلس بين يدك الخصمان فلا تقضين، حتى تسمع من الآخر، كما
سمعت من الأول

“Apabila datang dua orang yang bertelingkah duduk di hadapan kamu, **jangan sekali-kali kamu menghukum sehingga kamu mendengar hujah pihak yang kedua sepertimana yang pertama.**”

- [21] Nas tersebut turut selari dan bertepatan dengan maxim perundangan *audi alteram partem* yang bermaksud mendengar keterangan dan hujah kedua belah pihak. Dengan kata lain, kedua-dua pihak diberikan hak yang sama untuk mengemukakan keterangan dan hujah mereka di hadapan hakim.

Melalui prinsip ini, juga seseorang hakim dapat menghakimi sesuatu kes dengan adil dan saksama dan bukan semata-mata berdasarkan keterangan satu pihak saja yang boleh mengundang risiko kepada keputusan berat sebelah. Justeru, pada hemat kami adalah lebih cermat dan selamat sekiranya ruang untuk pihak-pihak berhujah diberikan.

KESIMPULAN

- [21] Sungguhpun alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan tatacara, namun pada hemat kami ia gagal dibuktikan telah menyebabkan berlakunya kecacatan prosedural yang bertentangan dengan undang-undang mahupun hukum Syarak untuk diberi pertimbangan. Justeru, prosiding interim hadanah yang telah difailkan oleh pihak Responden hendaklah diteruskan dengan YA Hakim Bicara membuat keputusan berkenaan pemakaian seksyen 118 ETMMS setelah meneliti hujahan kedua-dua pihak.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti notis permohonan dan affidavit sokongan Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

1. Permohonan semakan Pemohon adalah **DITOLAK**.
2. Arahan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam pada 14/3/2024 dalam prosiding kes Permohonan No.: 2312-H0610-431-0829 berhubung dengan pemfailan hujahan **DIKEKALKAN**.

Penghakiman ini dibaca dan ditandatangani oleh;

.....
1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

.....
2. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

.....
3. **YA DATO' ABAS BIN NORDIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor